

1034184-92.2019.8.26.0100

Classe: Tutela Antecipada Antecedente

Assunto: Liminar

Magistrado: Andre Salomon Tudisco

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Cível

Vara: 1ª VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE ARBITRAGEM

Data de Disponibilização: 03/10/2022

... e o desestímulo de comportamentos oportunistas prejudiciais ao tráfico. O princípio do "pacta sunt servanda" mostra-se necessário ao giro mercantil na medida em que freia o natural oportunismo dos agentes econômicos" (op. Cit., p. 111). Mais ainda, "As partes sabem que, estabelecido o vínculo do acordo, as vontades devem orientar-se segundo um princípio geral, mais forte e mais ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Central Cível

1ª VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE ARBITRAGEM

Praca Doutor Joao Mendes, S/N, São Paulo - SP - cep 01501-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1034184-92.2019.8.26.0100 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1034184-92.2019.8.26.0100

Classe - Assunto

Tutela Antecipada Antecedente - Liminar

Requerente:

Transfolha - Transporte e Distribuição Ltda.

Requerido:

Jose Inacio Soto Floriano

Juiz de Direito: Dr. Andre Salomon Tudisco

Vistos.

TRANSFOLHA - TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO LTDA. ajuizou tutela de urgência em caráter antecedente" em face de JOSÉ INÁCIO SOTO FLORIANO. Alega, em síntese, que as partes formalizaram contrato de franquia em dezembro de 1998, sendo recentemente renovado. Diz que o requerido noticiou a rescisão do contrato e está descumprimento cláusulas contratuais de exclusividade e não-concorrência. Assim, requer tutela de urgência para estender a vigência do contrato por mais 60 dias, bem como a imposição do cumprimento das obrigações contratuais de exclusividade e não-concorrência, A inicial (fls. 01/27) veio acompanhada dos documentos de fls. 28/156.

Houve a concessão da tutela de urgência (fls. 158/160).

Opostos embargos de declaração pelo requerido (fls. 164/187), não sendo acolhidos pela r. decisão de fls. 266/267

Emenda à inicial (fls. 225/251), apresentando o pedido principal consistente em obrigação de fazer com cobrança. Alega que, ante a rescisão do contrato por culpa do requerido, devem ser observadas as cláusulas de exclusividade e não-concorrência, bem como o pagamento das multas contratuais. Foram juntados os

documentos de fls. 252/265

O requerido apresentou contestação com reconvenção (fls. 316/378). Alegou, em síntese, que integra o sistema de franquia da ré, por imposição desta, pois era distribuidor e foi obrigado a aceitar a nova modalidade contratual. Sustenta que houve irregularidade na apresentação da COF. Aduz que no decorrer do contrato a franqueadora não cumpriu com sua obrigação de transferência de know-how. Diz que os números apresentados pela franqueadora não condiziam com a realidade financeira da unidade. Alega que a ré praticava reajustes sobre a tabela de remuneração das entregas em prejuízo à parte autora, sem qualquer negociação das partes. Defende a anulação do contrato de franquia firmado entre as partes, fundado no desvio de finalidade, vez que com a exclusividade, sob o título de franquia, a autora transfere à parte ré sua própria atividade, tomando características de representação sob forma de filial, o que caracteriza o desatendimento dos artigos 3º e 4º da Lei nº 8.955/1994, em razão da ausência de apresentação dos balanços e demonstrativos financeiros da empresa franqueadora, e da apresentação tempestiva da circular de oferta de franquia e deficiência de informações acerca do objeto da franquia. Pleiteia, assim, a resolução do contrato, por culpa exclusiva da autora, bem como a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais, morais e inaplicabilidade da cláusula de barreira à parte autora. Juntou documentos de fls. 379/845.

Réplica a contestação a reconvenção a fls. 975/987.

As partes se manifestaram sobre a produção de provas.

É o relatório. Fundamento E DECIDO.

A ação comporta julgamento, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, vez que o feito prescinde de dilação probatória, tratando-se de relação contratual, sendo a prova exclusivamente documental.

No mérito, o pedido principal é parcialmente procedente e o reconvenicional parcialmente procedente.

No que tange à extensão do prazo contratual, após pedido de rescisão por parte do réu-reconvinte, deve ser acolhida.

O contrato de franquia celebrado entre as partes prevê, em sua cláusula 52.1, que necessariamente, e de forma prévia à rescisão contratual, as partes deverão proceder a tratativas extrajudiciais pelo período de 45 dias para buscar uma solução amigável. No insucesso, deverão, também necessariamente, instituir mediação, que deverá ser resolvida pelo período de 02 meses.

O instrumento prevê, portanto, que as partes deverão manter o negócio formalizado ao menos por 2 meses e 45 dias antes que uma eventual rescisão tome corpo, a contar da declaração de vontade por uma delas sobre o fim da relação contratual.

Além disso, aplicável, por analogia, o art. 473 do Código civil, que dispõe: "A rescisão unilateral, nos casos em que a lei expressa ou implicitamente o permita, opera mediante denúncia notificada à outra parte."

Com efeito, o período de vigência da relação contratual entre as partes e a dimensão do trabalho logístico necessário para execução dos serviços prestados pelo requerido-reconvinte, para o qual não há substituto imediato, impõem que deve ser dado prazo razoável para a descontinuidade da prestação do serviço, inclusive pelas consequências irremediáveis que podem acometer a imagem da autora-reconvinda no mercado e a possível perda de clientes e, conseqüentemente, receita.

Portanto, deve ser acolhido o pedido para que o prazo de vigência do contrato seja estendido por 60 dias, ou seja, até 17.05.2019, obrigando o requerido a permanecer com seus serviços de entrega, sob pena de multa diária de R\$2.000,00 (dois mil reais) a contar de sua inequívoca intimação.

Sobre a rescisão do contrato, verifica-se que não houve culpa da autora-reconvinda. Resta incontroverso nos autos que as partes mantinham relações contratuais desde o ano de 1998, bem como que o contrato objeto da demanda foi renovado em 10 de janeiro de 2019, ou seja, pouca antes do réu-reconvinte ter notificado sobre seu desfazimento.

Nesse passo, em que pese a necessidade de cumprimento do disposto no artigo 4º, da Lei 8.955/1994, requisito objetivo para a validade do contrato, vê-se que a apresentação intempestiva não impossibilitou o exercício da atividade por anos, o

que implica em sua convalidação tácita, a teor do disposto no artigo 174 do Código Civil ("É escusada a confirmação expressa, quanto o negócio já foi cumprido em parte pelo devedor, ciente do vício que o inquilvana").

Nesse sentido:

"Apelação. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. Franquia. Pretensão fundada em suposto inadimplemento contratual e violação à Lei n. 8.955/64. Improcedência. Ausência de comprovação da falta de assessoria adequada pela franqueadora. Falta de entrega da Circular de Oferta de Franquia (COF) e manuais. Hipótese de anulação do negócio jurídico. Manutenção da exploração da franquia durante anos e ausência de demonstração de prejuízos advindos da omissão de informações constantes de tais documentos. Convalidação tácita (CC, art. 174). Boa-fé objetiva. Ausência de registro da marca junto ao INPI. Irregularidade formal que, sem outros elementos, não autoriza a rescisão do contrato por culpa da franqueadora. Precedentes. Violação da CLÁUSULA DE EXCLUSIVIDADE de operação. Ausência de infração contratual, por ser posterior à ruptura dos contratos pela franqueadora. Inadimplemento que partiu dos franqueados. Reconhecimento pela sentença. Ausência de impugnação específica. ESCOLHA DO PONTO. Responsabilidade dos franqueados. Franqueadora que apenas analisa a viabilidade para o exercício da atividade-fim. ROYALTIES. Cobrança que não configura venda casada, mas remuneração pela exploração da franquia. Previsão contratual. Sentença mantida. Recurso improvido". (Apelação 0023048-54.2011.8.26.0405; Rel.: Hamid Bdine; 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial - TJSP; j. 09/05/2018)

A alegação de anulação por ausência de apresentação da Circular de Oferta de Franquia ou, ainda, o conteúdo de suas informações deveriam ter sido objeto de insurgência no momento da contratação, não sendo lícito ao réu-reconvinte invocar sua anulação após decorridos muitos anos de sua execução, alegando que o insucesso do negócio se deu por tais circunstâncias.

Não é crível que o requerido-reconvinte, que exerce atividade empresarial e mantém relacionamento contratual com a ré por muitos anos, tenha firmado contrato de franquia, com posterior renovação, sem as cautelas necessárias, seja de natureza jurídica ou contábil, para a realização do empreendimento empresarial.

Nessa esteira, a transferência do know-how igualmente se presume, porquanto executa dos serviços objeto da franquia há anos.

Não se vislumbra, ainda, a ocorrência de desvio de finalidade, porquanto as atividades do réu-reconvinte na execução dos serviços franqueados correspondem exatamente ao objeto do contrato firmado, bem como ele prevê a utilização da marca de titularidade da autora "TRANSFOLHA", conforme previsto no artigo 2º da Lei 8.955/94, estabelecendo o contrato de forma clara as condições dos serviços prestados,.

Sobre a exclusividade questionada, consiste em opção dos contratantes.

Como ensina Paula Forgioni, o funcionamento do mercado exige que os pactos sejam respeitados, de forma que "A força obrigatória dos contratos viabiliza a existência do mercado, coibindo o oportunismo indesejável das empresas" (in Contratos Empresariais. Teoria e Aplicação, 5ª ed., p. 111, São Paulo, RT, 2020).

Ainda sobre o pacta sunt servanda, a doutrinadora aponta que "Se lhes fosse permitido, os agentes econômicos valer-se-iam dos contratos para vincular apenas seus parceiros comerciais, e nunca a si próprios. No momento inicial, as partes creem que o negócio ser-lhes-á vantajoso; todavia, com o passar do tempo, é possível que o vínculo deixe de interessar a uma delas. Nasce anseio de se livrar da amarra contratual para seguir outro caminho. Partindo dessa premissa, compreende-se a importância sistêmica da força vinculante dos contratos; na sua ausência, seria impossível a coibição do descumprimento da palavra empenhada e o desestímulo de comportamentos oportunistas prejudiciais ao tráfico. O princípio do "pacta sunt servanda" mostra-se necessário ao giro mercantil na medida em que freia o natural oportunismo dos agentes econômicos" (op. Cit., p. 111).

Mais ainda, "As partes sabem que, estabelecido o vínculo do acordo, as vontades devem orientar-se segundo um princípio geral, mais forte e mais constante do que os mutáveis interesses individuais. Nesse esquema, a liberdade [autonomia privada] é sacrificada em prol da segurança, da previsibilidade [ou da "segurança externa"]".

(...) Ao contratar, uma parte tem a legítima expectativa de que a outra comportar-se-á de determinada forma, daquela maneira anônima e repetida a que fizemos referência. Ambos os empresários planejam sua jogada e esperam que o outro "aja" de acordo com esse padrão "de mercado". Não é desejável que seja dada ao contrato interpretação diversa daquela que pressupõe o comportamento normalmente adotado [usos e costumes]. Isso levaria ao sacrifício da segurança e da previsibilidade jurídicas" (op. cit., pp. 121/122).

Ainda nesse sentido, é importante observar que "Por conta da adoção do padrão de comportamento do homem ativo e probo, ou dos "comerciantes cordatos", o ordenamento jurídico autoriza a pressuposição de que o agente econômico, de forma prudente e sensata, avaliou os riscos da operação e, lançando mão de sua liberdade econômica, vinculou-se. O sistema supõe que, naquele momento, o mercador entendeu que o contrato ser-lhe-ia vantajoso; essa expectativa pode até restar frustrada e aí reside o "risco do negócio"" (op. cit., p. 123).

O que se extrai dos autos é a existência de relação contratual de franquia, que obteve resultados positivos e negativos em momentos distintos, sendo que aqueles primeiros decorrem de risco do negócio, não sendo lícito à ré-reconvinte, pleitear sua anulação após executá-los por anos.

Assim, há de se observar que o contrato foi firmado livremente entre as partes, com o pleno conhecimento de suas condições, sendo de rigor a observância do princípio pacta sunt servanda, vez que inexistente fato superveniente imprevisível e extraordinário, que autorize eventual alteração de suas disposições.

Nesse sentido:

"Franquia - Contrato - Anulação ou rescisão - Invalidade do contrato e descumprimento contratual da franqueadora não demonstradas - Insucesso - Risco da atividade - Indenização por danos materiais e morais - Descabimento - Verba honorária - Redução - Aplicação do artigo 85, §8º do CPC de 2015 - Recurso provido em parte."

(Apelação 1026836-31.2016.8.26.0196; Rel.: Fortes Barbosa; 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial - TJSP; j. 02/07/2018)

"FRANQUIA - Propositura de ações de indenização pela autora (principal) e pela ré (reconvenção) - Desacolhimento dos pedidos iniciais - Impossibilidade de anulação do contrato, quer por descumprimento do disposto no "caput" do artigo 4º da Lei nº 8.955/94, quer com base em qualquer outro vício ou defeito supostamente encerrado pela circular de oferta de franquia - Não se evidencia existência de vício resultante de dolo - Negócios jurídicos que são anuláveis, por dolo, quando este for a sua causa - Inexistência de demonstração de prejuízo efetivo, sofrido pela ré, em virtude da inobservância da formalidade prevista no art. 4º da Lei nº 8.955/94 ou de qualquer outro vício ou defeito presente no instrumento contratual - Prova dos autos que evidencia que os prejuízos aventados pela demandante decorreram do insucesso do negócio, que não pode ser tributado à ré, o mesmo podendo ser dito em relação à decepção com os lucros por aquela almejados - Confirmação do negócio jurídico, diante do que restou sanada, tacitamente, eventual causa de anulabilidade - Precedentes - Ausência de elementos da responsabilidade civil, a impedir o acolhimento das pretensões indenizatórias - Hipótese de resilição bilateral (distrato) - Confirmação da bem fundamentada sentença recorrida - Recurso improvido, com observação." (Apelação 1085637-39.2013.8.26.0100; Rel.: Caio Marcelo Mendes de Oliveira; 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial - TJSP; j. 09/04/2018)

Ademais, os próprios documentos apresentados demonstram seguramente, que o pedido de rescisão decorre do simples fato da requerida-reconvinte ter contratado com terceiro.

Em relação à cláusula de não-concorrência, deve ser reconhecida a nulidade.

O colendo Superior Tribunal de Justiça já proclamou que são válidas as cláusulas contratuais de não-concorrência desde que limitadas espacial e territorialmente.

Senão vejamos:

"RECURSO ESPECIAL. DIREITOCIVIL. CONTRATO EMPRESARIAL ASSOCIATIVO. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AFASTADA. PEDIDO E CAUSA DE PEDIR. TEORIA DA SUBSTANCIAÇÃO. JULGAMENTO EXTRAPETITA. NÃO CARACTERIZADO. EXTINÇÃO DO

VÍNCULO CONTRATUAL. CLÁUSULA DE NÃO CONCORRÊNCIA. LIMITE TEMPORAL E ESPACIAL. ABUSIVIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Demanda em que se debate a validade e eficácia de cláusula contratual de não concorrência, inserida em contrato comercial eminentemente associativo.

[...]

5. A funcionalização dos contratos, positivada no art. 421 do Código Civil, impõe aos contratantes o dever de conduta proba que se estende para além da vigência contratual, vinculando as partes ao atendimento da finalidade contratada de forma plena.

6. São válidas as cláusulas contratuais de não-concorrência, desde que limitadas espacial e temporalmente, porquanto adequadas à proteção da concorrência e dos efeitos danosos decorrentes de potencial desvio de clientela valores jurídicos reconhecidos constitucionalmente.

7. Recurso especial provido" (REsp 1.203.109, 3ª Turma, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, julg. 05.05.2015, DJe 11.05.2015).

A cláusula 41 do contrato tem limitação temporal e territorial.

Porém, a referida limitação territorial é excessivamente genérica ao impedir o exercício da atividade num "raio de 300(duzentos) Km de qualquer unidade franqueada da TRANSFOLHA" (fls. 78).

Como ensina Fábio Ulhoa Coelho: "As cláusulas contratuais de disciplina da concorrência podem ou não ser válidas, de acordo com uma série de fatores, a serem especificamente analisados. Para a análise, o critério mais relevante é o da preservação do livre mercado. Ou seja, as partes podem disciplinar o exercício da concorrência entre elas, desde que não a eliminem por completo. Em outros termos, a validade da disciplina contratual da concorrência depende da preservação de margem para a competição (ainda que futura) entre os contratantes; ou seja, da definição de limites materiais, temporais e espaciais. Em concreto, a vedação não pode dizer respeito a todas as atividades econômicas, nem deixar de possuir delimitações no tempo ou no espaço. Em relação aos limites materiais, observa-se que a cláusula disciplinando a concorrência é inválida, se impede o contratante de explorar qualquer atividade econômica. A restrição deve necessariamente se circunscrever a determinados ramos de comércio, indústria ou serviços. Para as demais atividades, as partes ficam livres de qualquer obrigação (de não fazer). A propósito da restrição material, deve-se também considerar inválida a cláusula que impeça o contratante, pessoa física, de exercer a sua profissão. Por exemplo, o sócio que se desliga de sociedade de engenheiros pode, no instrumento de cessão de cotas, ficar impedido de competir com a sociedade, desde que os termos contratados não alcancem todas as atividades de engenharia para as quais o retirante se encontra profissionalmente habilitado ou preparado. Também é inválida a cláusula que vede a concorrência para sempre ou em qualquer lugar. Limites temporais ou espaciais são exigidos, para que a restrição contratada não importe eliminação total da concorrência. Trata-se, aqui, de uma alternativa inclusiva; quer dizer, o contrato pode prever limite no tempo e no espaço, ou só num deles. A restrição contratual limitada apenas geograficamente se considera feita para sempre, enquanto a limitada apenas no tempo alcança todos os mercados (Ripert-Roblot, 1947:350). A invalidade existe quando não há simultaneamente limite temporal e espacial. É igualmente inválida a cláusula de não concorrência que estabelece prazo demasiado longo, ou defina limites espaciais exagerados, que ultrapassem o potencial de conquista de mercado que as partes possuem. Desse modo, é nula a cláusula de não estabelecimento que o empreendedor de shopping center, para evitar a concorrência autofágica, contrata com os lojistas, quando os limites territoriais nela referidos extrapolam os do mercado sobre o qual pode exercer atração" (in Curso de Direito Comercial, v. 1, cap. 7, São Paulo, RT, 2018 - grifado)'"

Ora, da forma como estabelecida, o requerido-reconvinte estará proibido de exercer atividade em todo território nacional, vedação que vai contra os princípios constitucionais da livre iniciativa (art. 1º, inciso IV e art. 170, IV da CF) e livre exercício profissional (art. 5º, XIII, CF).

Portanto, deve ser reconhecida a abusividade e, conseqüentemente, a nulidade da

cláusula de não-concorrência, não sendo devida qualquer indenização por seu descumprimento.

Sendo reconhecida rescisão sem justa causa pelo requerido-reconvinte, é o caso de aplicação da cláusula penal, nos termos da cláusula 47 do contrato (fls. 80). Consequentemente, não há que se falar em qualquer responsabilidade da autora-reconvinda pelo pagamento de indenização ao réu-reconvinte.

Assim, o réu-reconvinte deverá pagar indenização "equivalente 1/3(um terço) das remunerações obtidas na média das 3 (três) últimas quinzenas", no valor de R\$43.272,53.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido pleiteado na exordial para que JOSÉ INÁCIO SOTO FLORIANO cumpra o contrato por mais 60 dias, ou seja, até 17.05.2019 e pague cláusula penal no valor de R\$43.272,53, com juros de mora, de 1% ao mês, e correção monetária, nos termos da tabela prática do TJSP, desde o encerramento do contrato. JULGO PARCIALMENTE o pedido reconvenicional, para reconhecer a nulidade da cláusula de não-concorrência, nos termos da fundamentação. Em razão da sucumbência mínima da autora-reconvinda na ação principal, condeno o réu-reconvinte ao pagamento das custas, despesas processuais, atualizadas desde o desembolso, e dos honorários advocatícios, que arbitro em 20% sobre o valor da condenação.

Em razão da sucumbência mínima da autora-reconvinda na reconvenção, condeno o réu-reconvinte ao pagamento das custas, despesas processuais, atualizadas desde o desembolso, e dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor atribuído à causa.

P.R.I.

São Paulo, 03 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA